

犯罪与道德

Crime and Morality 法律道德主义与刑法的界限

本指南讨论一个基础问题：国家能否仅仅因为某种行为“不道德”，就把它规定为犯罪？法律道德主义（legal moralism）认为，道德错误可以成为入罪的独立理由。但是，如果多数人的道德偏好自动变成刑法，少数群体的自由、隐私与平等就可能受到威胁。

理解本主题时，首先要把“不赞成一种行为”和“用国家刑罚制裁这种行为”分开。一个人可以认为某种行为错误，却同时反对警察、检察机关和监狱介入。刑法是国家最强的强制手段，因此必须说明为什么非用刑法不可。

这是一份独立的 Legal English 学习指南。它按步骤解释 legal moralism、Wolfenden Report、Hart–Devlin debate、Shaw v DPP 和 Knuller v DPP，并保留核心英文术语，帮助没有法律基础的英语专业学生理解视频。

学习目标 Learning objectives

- 理解 legal moralism（法律道德主义）并区分其强版本与温和版本。
- 比较 legal moralism 与 harm principle（伤害原则）理解二者可以重叠，但理由不同。
- 说明 Hart–Devlin debate（哈特—德夫林之争）以及它与 Wolfenden Report 的关系。
- 掌握 Shaw 与 Knuller 两案并看懂普通法法院“创造犯罪”所引起的争议。
- 使用一套清楚的方法分析犯罪、道德、隐私与公共利益之间的关系。

第一步 先理解什么是入罪 Criminalisation

Criminalisation 指的是：某种行为是否应当被规定为犯罪。这是一个“立法之前”的问题。它与“被告是否已实施犯罪”以及“定罪后应判什么刑”不同。

为什么必须区分？因为刑法会带来调查、逮捕、起诉、定罪、刑罚和社会污名。行为令人反感，并不能直接推出国家应使用这些强制手段。

问题	它在问什么	例子
Criminalisation 入罪	这种行为是否应成为犯罪？	通奸是否应当入罪？
Liability 刑事责任	被告是否构成现有犯罪？	actus reus 与 mens rea 是否已被证明？
Punishment 刑罚	定罪以后应如何处罚？	罚金、社区命令还是监禁？

法律道德主义主张什么

Legal moralism 的基本主张是：行为的不道德性可以成为将其入罪的理由。在最强的版本中，即使没有另外证明该行为伤害了他人，严重的道德错误本身也可能足以支持刑事禁止。

但是，法律道德主义并非只有一种形式。强版本把严重的不道德性看作可能充分的理由；温和版本只把它当作一个相关理由，还要求公共性、伤害、必要性或比例原则等限制条件。

理论版本	基本主张	核心困难
Strong legal moralism 强法律道德主义	严重的不道德行为本身可以支持入罪。	由谁确定“不道德”？国家为什么可以处罚？
Moderate legal moralism 温和法律道德主义	不道德性可以考虑，但还必须满足其他条件。	哪些限制条件能够防止任意使用刑法？

法律道德主义与伤害原则

理论	主要正当理由	首先要问的问题
Harm principle 伤害原则	防止对他人造成伤害	谁受到了什么伤害？伤害有多严重、多可能？
Legal moralism 法律道德主义	防止或谴责严重的不道德行为	违反了什么道德标准？刑法为什么可以执行它？

两种理论可以同时适用于同一个行为。谋杀既严重伤害他人，也被认为严重不道德。伤害原则和法律道德主义都能解释为什么谋杀应受刑罚。

真正的分歧出现在边界案件。如果成年人在私人空间自愿实施某种行为，并且没有明确伤害他人，国家还能否只因为多数人认为它不道德而处罚？这正是本主题的核心。

讨论道德以前必须区分四件事

- **Immoral 不等于 criminal**。对朋友撒谎、背叛伴侣或自私自利可能是不道德的，但未必构成犯罪。
- **Moral disapproval 不等于 harm**。感到厌恶或被冒犯，并不自动等于权利或利益受到法律意义上的伤害。
- **Public morality 不等于客观真理**。多数人接受的规则仍可能不公正、歧视少数群体，或者建立在错误认识之上。
- **Decriminalisation 不等于赞成**。不再使用刑罚，只表示国家不予起诉；公民仍可以在道德上批评该行为。

到底是谁的道德 Whose morality

Public morality（公共道德）这个表达可能隐藏不同标准。它可能指社会实际上接受的规则、普通理性人的判断、宗教教义、宪法价值， 或者通过理性论证得到的道德原则。这些标准并不一定得出相同结论。

H L A Hart 区分 positive morality 与 critical morality。Positive morality 是一个社会实际接受的道德；critical morality 是我们用来评价这些现有观念是否合理、公正的标准。多数人赞成一条规则， 并不能证明这条规则就是正确的。

概念	含义	为什么重要
Positive morality 实存道德	社会成员事实上普遍接受的道德标准	告诉我们社会“相信什么”， 但不能证明它正确
Critical morality 批判道德	用于反思和评价现有道德观念的标准	允许我们批评传统、偏见和多数人的错误

道德会变化 Moral change

社会态度不是固定不变的。曾经被谴责甚至入罪的行为， 后来可能被视为私人生活或平等公民权的一部分。如果刑法只跟随当时多数人的情绪， 少数群体就可能在偏见得到反思以前受到处罚。

通奸说明了另一个问题。很多人认为背叛伴侣严重不道德， 也可能造成情感伤害；但这并不自动说明警察调查、刑事起诉和监禁是适当的手段。道德评价与刑法规制必须分别论证。

私人行为与公共行为

发生在私人空间的行为并不自动免除刑事责任。谋杀和家庭暴力也可能发生在家中， 但它们直接伤害他人。因此， 关键不是行为“在哪里”， 而是它是否伤害他人、侵犯权利或造成真正的公共问题。

最困难的是成年人之间自愿的私人行为。如果当事人具有同意能力、真正自愿， 并且没有独立伤害， 入罪理由就更多依赖 moralism、paternalism（家长主义）或 offence to others（冒犯他人）。分析时必须把这些理由分开。

Wolfenden Report 沃尔芬登报告

1957 年的 Wolfenden Report 研究了英国的同性性行为犯罪与卖淫问题。报告建议：成年人之间自愿、私下的同性性行为不应继续构成犯罪。它区分了法律可以维护的 public order and decency（公共秩序与公共体面）， 以及通常不应由法律干预的 private morality（私人道德）领域。

报告并没有宣布所有私人行为在道德上都是正确的。它只是把个人的道德判断与国家的刑事禁止分开。这个区分后来成为 Hart–Devlin debate 的直接起点。

Hart Devlin debate 哈特—德夫林之争

争论的中心问题是：社会能否使用刑法维护共同道德？Patrick Devlin 强调共同道德对于社会结合的重要性；H L A Hart 强调个人自由，并要求证明私人不道德行为确实会危害社会。

Patrick Devlin 的观点

- 社会不仅由领土和政府组成，也有共同的道德结构。共同道德帮助社会成员形成一个共同体。
- 对共同道德的严重攻击可能破坏社会凝聚力。因此，私人行为并非永远与社会无关。
- 法律可以保护社会的道德环境。正如社会可以抵御政治颠覆，它也可以保护自身延续所需要的道德基础。
- 公共道德应从 **reasonable member of society** 的稳定判断中识别。标准不是某一位法官个人的偏好，而是普通社会成员或陪审团所代表的共同判断。
- Devlin 并未主张处罚每一种恶习。容忍、隐私、行为的严重程度以及执法成本仍然是限制因素。

H L A Hart 的观点

- 社会解体需要证据。存在共同道德，并不能证明每一次偏离都会威胁社会生存。
- 多数人的感受并不充分。厌恶、愤怒和传统只能说明 **positive morality**，不能单独证明处罚在理性上正当。
- 自由具有独立价值。调查、起诉和惩罚本身也会造成伤害；国家干预私人选择需要比“我们不喜欢它”更强的理由。
- 社会必须允许批判现有道德。如果多数人的观念自动成为刑法，不公正的传统就难以改变，少数群体也会特别脆弱。
- 伤害与其他公共理由可以构成界限。Hart 并非认为所有私人行为都不可干预；真正伤害他人的行为仍可受到法律制裁。

双方分歧一览

问题	Devlin	Hart
什么使社会结合在一起？	共同道德是社会纽带的一部分。	共同规则重要，但社会生存不要求道德完全一致。
私人不道德行为能否成为法律问题？	可以，如果它严重威胁共同道德。	不能只因为多数人谴责它。
谁的判断重要？	合理社会成员的稳定共同判断。	被接受的道德本身也必须接受批判。

最大的危险是什么？	道德瓦解与社会凝聚力丧失。	强制、不宽容与对少数群体的压迫。
-----------	---------------	------------------

Shaw v Director of Public Prosecutions

Shaw v DPP 1962 AC 220

案件事实 Facts：Shaw 出版并出售 Ladies Directory。目录包含妓女提供的联系方式、照片和描述，他还向被收录者收费。除成文法犯罪外，他还被控 conspiracy to corrupt public morals（共谋败坏公共道德）。

法律问题 Legal issue：即使议会没有通过成文法明确创设这一罪名，英格兰法中是否已经存在“共谋败坏公共道德”这一普通法犯罪？

判决 Decision：英国上议院驳回上诉，维持定罪。多数意见承认这一普通法罪名，并认为法院对于损害公共福祉的行为仍保有某种剩余责任。

案件意义 Why the case matters：本案把法律道德主义与 judicial lawmaking（司法造法）联系起来。法院声称可以保护公共道德，但也产生合法性疑问：如果行为发生以后法院才承认一个新罪名，公民怎样预先知道什么是犯罪？

合法性原则 The principle of legality

刑法必须足够明确，并且原则上只能面向未来适用。公民应当能够在行动以前知道哪些行为构成犯罪。

corrupt public morals 这类宽泛表达在定义、预见可能性和一致执法方面都会造成困难。

这里还有一个制度问题。在现代民主制度中，议会能够调查、公开辩论并清楚界定新罪名。法院创造犯罪可能以不确定的道德判断代替公开立法。

Kneller Publishing Printing and Promotions Ltd v DPP

Kneller v DPP 1973 AC 435

案件事实 Facts：被告与 International Times 有关。该报刊登男同性恋者寻找性接触对象的广告。被告因 conspiracy to corrupt public morals（共谋败坏公共道德）和 conspiracy to outrage public decency（共谋严重冒犯公共体面）而被定罪。

法律问题 Legal issue：法院是否应推翻 Shaw？这些普通法共谋罪是否适用于有关广告？

判决 Decision：英国上议院没有推翻 Shaw，并维持定罪。但是，各位法官的意见显示，他们对 Shaw、判例拘束力以及司法权界限存在严重分歧。

案件意义 Why the case matters：Kneller 在当时确认了 Shaw 的效力，但没有承认法院可以无限制地创造犯罪。今天，本案常与这一原则联系：法院不应创设新的刑事犯罪；把原本不构成犯罪的行为规定为犯罪，主要属于议会的职责。

纠正对 Knulier 的三个常见误解

- 它并不只是一个“关于同性恋”的案件。法律争点涉及广告出版、共谋、公共道德与公共体面。
- 第二项犯罪是 **conspiracy to outrage public decency**。不能误写成 **conspiracy to outrage public morals**。
- 本案没有赋予法院持续、一般性的“创造犯罪”权力。后来的判例强调，应由议会决定是否把原本非犯罪的行为规定为犯罪。

这些普通法共谋罪后来怎样了

Criminal Law Act 1977 第 5 条原则上废除了普通法上的共谋罪，但保留了狭窄例外。第 5(3) 条涉及这样的协议：所约定的行为倾向于败坏公共道德或严重冒犯公共体面，而一个人单独实施该行为时原本不构成犯罪。

这个条文不能被理解为处罚一切不道德行为的普遍许可证。它只涉及共谋法中非常具体、例外的领域。现代法院同时强调民主原则：应由议会，而不是法官，决定是否创设新的犯罪。

分析犯罪与道德的八个步骤

- 1 准确界定行为 **Define the conduct**。到底要禁止什么行为、遗漏、出版活动或协议？
- 2 找出道德主张 **Identify the moral claim**。据称违反了什么道德标准？为什么被认为错误？
- 3 把道德与伤害分开 **Separate morality from harm**。是否确实损害了他人的利益， 还是只有道德上的不赞成？
- 4 区分公共与私人因素 **Distinguish public and private dimensions**。是否涉及真实同意、剥削、不愿观看者或真正的公共影响？
- 5 追问正在执行谁的道德 **Ask whose morality**。标准来自证据和公共理性， 还是只来自多数人的情绪、传统或偏见？
- 6 检验合法性与权利 **Test legality and rights**。拟议罪名是否明确、面向未来， 并尊重隐私、平等与少数群体保护？
- 7 检验必要性与比例 **Examine necessity and proportionality**。民法、行政规制、教育或私人选择能否解决问题， 而不使用刑罚？
- 8 确认适当的法律制定者 **Identify the proper lawgiver**。议会是否已经规定明确罪名， 还是要求法院创造或扩张刑事责任？

四个例子怎样分析

行为	道德与伤害分析	入罪时的核心问题
Murder 谋杀	严重不道德， 并直接伤害他人的生命	道德理由与伤害理由高度重叠
Adultery 通奸	常被认为不道德， 也可能造成情感伤害	错误性是否足以证明警察和刑罚的介入？
成年人自愿的私人性行为	可能与部分道德或宗教观念冲突， 但不一定侵犯他人权利	多数人的反对与少数群体的自由
公开的性服务广告	可能涉及剥削、公共暴露、公共体面和伤害	应明确禁止的行为， 不能只依赖含糊的“道德”

Legal English 核心表达

英文术语	本主题中的中文含义	典型用法
public morals	被认为由社会共同接受的道德标准	conduct tending to corrupt public morals
public decency	对公开呈现于社会的行为所要求的最低体面标准	an outrage to public decency
conspiracy	两个或以上的人达成实施被禁止行为的协议	convicted of conspiracy
uphold a conviction	维持有罪判决	The House upheld the conviction.
dismiss an appeal	驳回上诉	The appeal was dismissed.
overrule	推翻先例，使原有法律规则不再具有权威	The court declined to overrule Shaw.
dissent	法官不同意多数意见的法律结论	A judge dissented.
judge-made law	通过法院判决发展形成的法律	a controversial judge-made offence

中国学生容易混淆的地方

- 误区一：把 **morality** 当成所有人都同意的客观事实。道德标准内部可能存在争议，也会随着社会变化。
- 误区二：认为 **decriminalisation** 就是国家赞成该行为。国家可以不使用刑罚，同时允许公民继续进行道德批评。
- 误区三：把 **offence** 或 **disgust** 直接等同于 **harm**。情绪反应在部分理论中有关联，但自动等于利益受损或权利被侵犯。
- 误区四：把 **Knulier** 说成直接处罚同性恋本身。案件的具体法律对象是广告出版以及普通法共谋罪。
- 误区五：认为英国法院今天仍有创造犯罪的一般权力。现代判例把创设新罪名的责任交给议会。
- 误区六：混淆 **public morals** 与 **public decency**。二者相关但不同，在 **Knulier** 中也是两项不同的共谋指控。

关键概念 Key terms

术语	简明定义
Legal moralism 法律道德主义	行为的不道德性可以成为将其入罪的理由
Positive morality 实存道德	某一社会事实上普遍接受的道德标准
Critical morality 批判道德	用于评价现有道德观念是否合理、公正的标准
Private morality 私人道德	对私人领域行为作出的道德判断
Public morality 公共道德	被认为与共同体有关或构成共同体基础的道德标准
Legal certainty 法律确定性	法律必须可以获得，并且足够清楚、可以预见
Common-law offence 普通法犯罪	由司法判例承认，而不是由成文法明确创设的犯罪

最后的结论

法律道德主义揭示了刑法中一个长期存在的张力。法律不能完全脱离道德判断；但是，仅凭道德上的不赞成，也可能产生含糊的罪名、侵入私人生活的执法以及对少数群体的歧视。

因此，好的分析绝不能只问“这种行为是否不道德”。还要问：有什么具体伤害或公共利益？正在执行谁的道德？规则是否明确且合乎比例？入罪决定应由议会作出，还是可以由法院发展？

资料与延伸阅读 Sources and further reading

Report of the Departmental Committee on Homosexual Offences and Prostitution, Cmnd 247, 1957.
Patrick Devlin, The Enforcement of Morals, Oxford University Press, 1965.
H L A Hart, Law Liberty and Morality, Oxford University Press, 1963.
Shaw v Director of Public Prosecutions 1962 AC 220.
Knulier Publishing Printing and Promotions Ltd v Director of Public Prosecutions 1973 AC 435.
Criminal Law Act 1977, section 5.
R v Jones 2006 UKHL 16.